

1501469-97.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Tribunal de Justiça Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501469-97.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501469-97.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219216/2022 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 26710323 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2219216 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Henrique de Lima Fernandes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

PAULO HENRIQUE DE LIMA FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por alegada prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 56-58):

No dia 11 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, na Estrada Caneleiras, altura do nº35, bairro Valo Velho, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 26 porções de maconha, com peso

líquido de 40g, 26 porções de crack, com peso líquido de 4g, e 8 porções de cocaína, com peso líquido de 3g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além de R\$ 179,05 em dinheiro trocado, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudos de constatação de fls. 12/14, e exame químico-toxicológico a ser oportunamente anexado ao feito.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado (fls. 93-94) e apresentou defesa prévia (fls. 91-92). Não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls 59-61).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, em debates orais, as partes se manifestaram.

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia, com o afastamento do redutor do art. 33, caput, uma vez que o réu já possui envolvimento com atividades ilícitas.

A defesa, por sua vez, pediu a aplicação da pena mínima com a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo questões preliminares pendentes de análise, passo direto ao mérito.

O caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em exame, há prova da materialidade do crime e de sua autoria.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de (fls. 9-10), laudos de constatação de fls. 12/14, pelo boletim de ocorrência de (fls. 5-7) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivos de (fls. 65-67).

A autoria também é certa. Vejamos a prova oral colhida.

A testemunha em comum, o Guarda Municipal JULIANO WALICEK MOELLER, disse em sede policial, que encontravam-se em patrulhamento de rotina, pela Rua Caneleiras, bairro Valo Velho - Chácara Santa Maria, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o indiciado, o qual ao visualizar a viatura da GCM, tentou empreender fuga, sendo detido. Ao revistarem o indiciado este trazia consigo nas mãos uma pochete, a qual no interior foi arrecadado 26 "trouxinhas", em embalagem plástica, contendo erva seca esverdeada, aparentando ser "maconha", bem como, 08 "eppendorf"s" contendo pó branco, aparentando ser "cocaína", 26 pedrinhas, envoltas em plásticos, possivelmente pela droga conhecida por "Crack, e ainda, a quantia de R\$ 179,05 em notas e moedas. Indagado dos fatos, o indiciado afirmou que estava vendendo a droga. O condutor arrecadou as drogas no local primário dos fatos, citados acima. Por fim, o conduziram o indiciado a presença da Autoridade Policial.

Também ouvido sob o contraditório, contou que estava em patrulhamento numa via que usa para se deslocar, um local perigoso, conhecido como ponto de tráfico. Deparou-se com o réu, com quem foi encontrada uma pochete com os entorpecentes dentro, além de uma quantia em dinheiro. Informalmente ele confessou que estava na venda de drogas. Quando o réu viu a viatura ele tentou fugir, por isso foi detido. Não viram nenhum ato de venda. Nunca o tinha visto.

A testemunha em comum, o Guarda Municipal EDILSON DE JESUS GÓIS, disse em sede inquisitorial "que encontravam-se em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de viatura, pela Rua Caneleiras, bairro Chácara Santa Maria, cujo local é um ponto de venda de drogas, quando notaram o investigado, que ao perceber a aproximação da viatura da GCM, tentou empreender fuga, sendo detido. Ao ser revistado, foi arrecadado com o suspeito uma pochete, a qual traziam uma das mãos, contendo 26 "trouxinhas", em embalagem plástica, contendo erva seca esverdeada,

aparentando ser "maconha", bem como, 08 "ependorf"s" contendo pó branco, aparentando ser "cocaína", 26 pedrinhas, envoltas em plásticos, possivelmente pela droga conhecida por "Crack, e ainda, a quantia de R\$ 179,05 em notas e moedas. Instado sobre as drogas que trazia consigo, o implicado, alegou informalmente, que ali estava vendendo drogas para possíveis compradores. Desta forma, o conduziram o indiciado a presença da Autoridade Policial".

Também ouvido sob o contraditório, contou que quando dos fatos estava em patrulhamento preventivo na área do Valo Velho. Essa rua é conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Ao passar por ali viram o réu, que ao avistar a viatura empreendeu fuga, desceu o escadão correndo, motivo pelo qual os guardas foram atrás. Com o réu encontraram uma pochete com drogas e dinheiro. O réu foi conduzido até a delegacia. Não o conhecia. Não visualizou atos de comércio.

Em seu interrogatório, o réu PAULO HENRIQUE DE LIMA FERNANDES, disse em sede policial, "que não tem advogado constituído. ficou avisada de sua prisão a sua genitora estela de lima souza, 11-95378-4945. quantos aos fatos, o interrogando diz que quando foi abordado estava na rua das caneleiras, panfletando a tarde estava indo embora resolveu parar em um bar próximo a um escadão, estava sendo na calçada do bar, quando chegaram os gcm's, um rapaz que estava no escadão correu deixando cair alguma coisa. ficou tranquilo foi abordado consigo só havia um valor em dinheiro o qual ganhou por 2 dias de panfletagem, porém os gcm's encontraram alguma coisa em uma bolsinha no escadão, chegaram e disseram que pertencia ao interrogando. o interrogando ficou quieto por medo, sendo então conduzido a esta delegacia de polícia".

Em juízo confessou os fatos, disse que saiu do trabalho e encontrou um amigo que o convidou para vender drogas. Ressaltou que não tem costume de fazer isso e que não fugiu dos guardas, e que somente resolveu vender drogas naquele dia para "se mostrar" para amigos.

Pois bem, percebe-se que ao fim da instrução não há qualquer dúvida sobre a procedência da ação penal, uma vez que sua confissão está em plena harmonia com as demais provas colhidas, sobretudo a palavra dos policiais.

Neste aspecto, o depoimento de agentes estatais, como se sabe, não possui presunção de veracidade absoluta, porém, quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar, justamente como na hipótese vertente, deve ser levado em consideração. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no STJ:

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe17/11/2016.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021).

Portanto, a prova colhida nos autos é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi ilícita, o réu era

imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

Assim, nos termos do art. 69 do CP, passo a dosimetria da pena.

Primeira etapa.

Consoante o preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06, a pena base do delito em análise é de 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, devendo ser analisadas em conjunto com as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade da conduta do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa, sempre levando em conta o que era exigível ao autor, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que a culpabilidade não exorbita o comum para o crime e análise.

O réu não possui antecedentes criminais, lembrando que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a sociedade, não foi suficientemente apurada nos presentes autos.

A personalidade do agente diz respeito à “sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor” (in: Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Ressalto ainda que, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, aqui devem ser considerados apenas aspectos extrapenais. E, por isso, entendo que não há informações suficientes para sua valoração.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime e também não fogem do comum para o já apenado pelo tipo incriminador.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Entendo que no caso em análise não extrapolam o habitual.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. Embora graves, não se mostraram anormais, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

E, considerando a natureza do delito, não há que se falar em comportamento da vítima.

Já em relação a quantidade e natureza da droga apreendida, observo que ambas as circunstâncias devem ser analisadas em conjunto. Neste sentido:

Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada –

TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020.

Portanto, não obstante tenham sido apreendidas drogas de alto poder viciante (cocaína e crack), considerando que a quantidade não se mostra exagerada, entendo que não haja razão para agravar a pena nesta fase.

Assim, considerando todas essas circunstâncias, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda etapa.

Incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, vale dizer, a da confissão espontânea.

Isso porque se a confissão do agente é utilizada pelo magistrado como fundamento para embasar a condenação, a citada circunstância atenuante deve ser aplicada em favor do réu (enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Vale observar que a atenuante deve incidir, “não importando que, em juízo, este tenha se retratado e negado o crime” (HC 176.405/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/04/2013).

Contudo, deixo de aplicar a redução porque “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Não estão presentes circunstâncias agravantes.

Assim, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa.

Presente a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas:

§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

No caso, o réu é primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Vale dizer ainda que a existência de inquéritos ou ações penais em cursos, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para afastar a aplicação do redutor, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 18/8/2022, nos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR, processos-paradigma do Tema n. 1139 com a seguinte tese:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, cabível a aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3.

Portanto, fixo a pena definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP):

Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e as condições pessoais do condenado, que não é reincidente, com fundamento no art. 33, parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, fixo, para início do cumprimento da pena, o regime aberto.

Esclareço que o regime em tela é cabível em razão de o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, ter firmado o entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP)

Deixo de realizar a detração nesse momento porque, em vista do regime aplicado não veria alteração.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP)

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na garantia constitucional da individualização da pena, declarou inconstitucional a vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos aos condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (HC 97256/RS, Rel. Min. Ayres

Britto).

Portanto, considerando o montante de pena aplicado, que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis e que o delito não foi cometido com grave ameaça ou violência, verifica-se a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritiva de direitos.

Assim sendo, substituto a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, devendo o Juízo da execução, em audiência admonitória, definir a entidade que será beneficiado com a prestação social alternativa, e prestação pecuniária no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, a ser pago à entidade a ser definida pelo juízo da execução, admitindo-se o parcelamento, conforme a situação financeira do réu.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP):

Resta prejudicado o sursis em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP)

Considerando a situação socioeconômica do sentenciado, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser reajustado a partir da data da prática do crime. A pena de multa deverá ser paga nos termos e nos prazos dispostos no artigo 50 do CP, sob pena de execução.

Possibilidade de recorrer em liberdade

Considerando a primariedade do réu, o montante de pena aplicado, o regime inicial fixado e a substituição da pena, o réu poderá apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu PAULO HENRIQUE DE LIMA FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito de prestação de serviços e prestação pecuniária.

Quanto ao dinheiro apreendido, DECRETO a sua perda em favor da UNIÃO, devendo o valor ser recolhido em favor do FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça, que ora concedo.

Proceda-se em relação as drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 05 de Outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA